Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas

Rua Afonso Tagliari, 40 - Bairro: Centro - CEP: 99900000 - Fone: (54) 304-69884 - 549-9996-4627-balcão virtual - Email: frgtvargas2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5000603-07.2022.8.21.0050/RS

REQUERENTE: GABRIEL PACHOLSKI (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))

REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

1. Relatório

GABRIEL PACHOLSKI, representada por seu genitor, ajuizou a presente ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**.

Aduziu ser portador de Paralisia cerebral quadriplágica espástica (CID10 – G80.0), razão pela qual necessita fazer uso de TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U PO SOL INJ, na quantidade de 02 frascos a cada 3 meses, por período indeterminado.

Referiu que o medicamento é imprescindível para sua existência digna. Mencionou que a família não possui condições financeiras para arcar com o tratamento, que deveria ser suportado pelo requerido. Pediu tutela de urgência. Juntou documentos (ev. 1).

Deferiu-se tutela de urgência para o fim de determinar que o demandado fornecesse o medicamento pleiteado, de acordo com receituários médicos, sob pena de bloqueio de valores (evento 14, DESPADEC1).

Citado (evento 29), o Estado apresentou contestação (evento 34, CONT1). Preliminarmente, requereu a intimação do autor para emendar a inicial e incluir a União como ré, conforme o art. 115, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do processo. Em caso de inadmissibilidade da preliminar, seja julgado improcedente o pedido.

Caso procedente o pedido, pediu seja autorizado o fornecimento pela Denominação Comum Brasileira e que o dispositivo exija que a parte autora comprove a necessidade de uso da medicação a cada 30 dias e permita o bloqueio do medicamento no sistema AME se o autor não o procurar após um mês. Além disso, requereu que o Estado não seja condenado a pagar custas e honorários.

O autor apresentou réplica. Sustentou não ser necessária a inclusão da União, pois não se trata de litisconsórcio passivo necessário e a responsabilidade dos entes é solidária (evento 62, PET1).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido (evento 77, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

2. Fundamentação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade *ad causam* para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.

Não prospera o argumento de ser obrigatória a inclusão da União.

A tese fixada no tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), em verdade, reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Nesse sentido:

> ***Ementa:*** *DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.* ***DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO.*** *TRASTUZUMABE DERUXTECANA (ENHERTU).* ***LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO CONFIGURADO.*** *OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO NA TPI NO RE Nº 1.366.243-SC (TEMA Nº 1.234).1. A questão acerca da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde tem gerado debates acirrados, notadamente no âmbito das Cortes Superiores. Por força destas contingências, a compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema têm causado entraves na prestação jurisdicional nas instâncias originárias.2. Na casuística, o nó górdio está em discernir a legitimidade passiva da* ***União*** *e a consectária competência da Justiça Federal na lide em que a parte beneficiária, ora agravada, postula o fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu) 100mg, por ser portadora de Neoplasia Maligna da Mama (CID C50.9).3. Diante dos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema na TPI no RE nº 1.366.243-SC (Tema nº 1.234),* ***considerando que se lida com demanda envolvendo o fornecimento de medicamentos registrado na ANVISA, mas não padronizados no SUS, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo, mormente porque a parte beneficiária elegeu demandar contra o Estado do Rio Grande do Sul, nos moldes do item 5.2 do referido aresto.4. Cabe ressaltar que quando da análise do caso concreto, houve***

o julgamento final do Tema nº 1.234 pelo STF, realizada na sessão virtual com início em 06SET24 e finalizada em 13SET24, sendo a tese materializada aplicada a partir da data da publicação do acórdão, por força da modulação de seus efeitos, a saber: (...)Em relação à competência, inicialmente, destaco que o caso em tela encontra-se dentro do período de modulação, não havendo que se falar em alteração de competência por força deste tema, em razão de o processo ter sido ajuizado anteriormente à data de publicação da ata deste julgamento.(...). 5. Todavia, o caso concreto deve ser julgado com as premissas fixadas, quando do julgamento da TPI no RE nº 1.366.243-SC (Tema nº 1.234).4. Precedentes desta e. Corte de Justiça conferidos e catalogados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 52663167620248217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 18-09-2024) grifei

Portanto, em que pese a medicação postulada não seja fornecida pelo SUS, de regulamentação da União, há legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos.

Considerando a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da presente ação, não havendo questões processuais pendentes, passa-se ao julgamento do mérito.

Mérito

Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, vez que desnecessária a produção de outras provas.

A controvérsia da lide cinge-se à responsabilidade do ente público demandado sobre o custeio do medicamento TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U PO SOL INJ para tratamento de paralisia cerebral de adolescente.

A matéria é relacionada à saúde pública, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados, derivada do art. 196 da Constituição Federal:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Com o julgamento do REsp nº 1.657.156 (Tema Repetitivo 106, STJ), restou estabelecida a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS quando preenchidos, cumulativamente os seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso dos autos, há laudo médico atestando a necessidade e a impossibilidade de substituição do tratamento postulado (evento 1, LAUDO11, evento 1, RECEIT12).

A parte autora é economicamente hipossuficiente (evento 1, DECLPOBRE8), sendo assistida pela Defensoria Pública.

Por último, encontra-se registrada junto à ANVISA.[1]

Assim, não há dúvidas acerca da obrigação do ente público demandado em fornecer a medicação postulada, devendo ser pontuado que a simples ausência da sua inclusão em listagens administrativas do SUS não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos, mormente se tratando de adolescente que goza de proteção integral.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADOS AO SUS POR PROTOCOLOS CLÍNICOS QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM ATESTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO FÁRMACO PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único

de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes: AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013; AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.2014; entre outros. 2. No que se refere à alegada violação do art. 19 e seguintes da Lei 8.080/90 e aos critérios adotados para admitir a necessidade e a adequação do medicamento ao paciente (paciente portador de metástase cerebral e pulmonar e formação de aspecto neoplástico no rim esquerdo), tanto o Juízo Monocrático (fls. 193/196) como o Colegiado a quo (fls. 249/254) entenderam estarem estas devidamente comprovadas. 3. Desse modo, a jurisprudência do STJ já orientou que é possível o fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS por protocolos clínicos quando o Tribunal de origem atestar a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.588.507/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.10.2016. 4. Ressalte-se, ainda que, segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir a União do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde. Precedente: AgInt no REsp. 1.522.409/RN, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg no REsp 1554490/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)

Dessa forma, mantenho a decisão liminar, no sentido de que o requerido forneça o medicamento TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U, de forma contínua, por tempo indeterminado, podendo ocorrer o fornecimento pela Denominação Comum Brasileira.

3. Dispositivo

Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **GABRIEL PACHOLSKI par CONDENAR** o Estado do Rio Grande do Sul, a fornecer de forma mensal, contínua e na quantidade e tempo que a autora necessitar, o medicamento TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U, podendo ocorrer o fornecimento pela Denominação Comum Brasileira.

Se tratando de tratamento contínuo, a dispensação e a quantia necessárias do fármaco referido deverão ser embasadas em laudo médico atualizado, a ser apresentado periodicamente (180 dias, a contar da última entrega, conforme Portaria GM/MS 111/2016), junto ao órgão da rede pública responsável pela entrega.

O cumprimento da condenação, provisório ou definitivo, deverá observar os termos do Ofício-Circular n.º 77/2019, que, no item 6, b, o qual determina que os cumprimentos de sentenças prolatadas no eproc deverão prosseguir com um novo número de processo, devendo o advogado providenciar a sua distribuição, a vinculação com o número do processo de conhecimento e a juntada dos documentos indispensáveis.

No que tange aos honorários, recentemente, o STF firmou o entendimento que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.[2]

Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, o Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, uma vez que nestas ações, em que se busca preservar, a vida, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte demandante.[3]

Sendo assim, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios ao FADEP que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação de serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cujo valor deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme previsto no §16 do referido artigo.

Sem custas e emolumentos (art. 141, §2º, ECA).

Considerando que a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do art. 496, §4º, II, do CPC vigente, não está a sentença sujeita a reexame necessário.

Em sendo opostos embargos de declaração, dê-se vista deles à parte embargada, para que, querendo, exerça o contraditório, em cinco dias (artigo 1.023, § 2°, do CPC). Após, voltem para julgamento.

No caso de ser interposto recurso de apelação é desnecessário o prévio juízo de admissibilidade pelo julgador de primeiro grau (artigo 1.010 do CPC), em consequência, intime-se imediatamente o recorrido para apresentar contrarrazões (§ 1º do artigo 1.010 do CPC).

Em seguida, no caso de apresentação de recurso adesivo, intime-se imediatamente o recorrido adesivo para apresentar as suas contrarrazões (§ 2º do artigo 1.010 do CPC).

Após as formalidades dos §§ 1º e 2º do artigo 1010 do CPC, contudo, os autos não poderão ser remetidos imediatamente ao Tribunal (§ 3º do artigo 1010 do CPC), em vista do princípio da especialidade que exige a aplicação do inciso VII do artigo 198 do ECA.

Portanto, em todos os processos em trâmite no Juizado da Infância e da Juventude, após o cumprimento dos §§ 1º e 2º do artigo 1010 do CPC, façam-se os autos conclusos por força do inciso VII.

No mais, após o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **MILENA MOTTA DE CARVALHO, Juíza de Direito**, em 27/9/2024, às 13:5:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10065759580v8** e o código CRC **90fef6e2**.

1. https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=1163701430028 ↩
2. STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/6/2023 (Repercussão Geral – Tema 1002) (Info 1100). ↩
3. Apelação Cível, Nº 50034034420238210059, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 20-02-2024. ↩